

제61회 변리사 시험 민사소송법 해설

By. 한빛 민사소송법 강사진

안녕하세요.

한빛 민소법 강사진입니다.

제61회 변리사 2차 시험이 끝났습니다.

우선, 올 한해간 수험공부하시느라 정말 수고 많으셨습니다.

올해 제61회 변리사 민사소송법 시험의 총평은, 논점은 어렵지 않았으나, 경우의 수와 시험 전반적 시간운용에 있어서 쉽지 않았다는 해설평을 남깁니다.

예년과 마찬가지로, 10점x10문제로 출제되었으며, 이러한 기초가 당분간 정착 내지는 반복 될 것으로 보입니다. 하지만, 15점 20점짜리 문제도 변칙적으로 출제될 수 있어서, 이 부분 도 소홀히하지 않을 것을 당부드립니다.

2024. 07. 28. 15:30.

김재진, 나지예, 정경대 드림.

문제	설문	논점
1	1	상소불가분 + 전부승소자의 항소이익
	2	소송상화해의 법적성질 + 기판력
	3	사문서의 형식적 증거력 + 백지문서
2	1	토지관할 + 전속적관할합의
	2	사물관할 + 이송가부
3	1	항소심 청구변경(추가적병합)
	2	대상청구 + 장래이행의 소
	3	불복하지않은 청구의 확정시기
4	1	변론주의 - 주장X 사실에 대한 판단 가부
	2	재판상자백 + 철회가부

*본 해설 자료는 강사진이 작성한 견해에 불과하므로 이의신청의 근거가 될 수 없습니다.

【 문제-1 】 (30점)

공통사실관계 : 乙의 불법행위로 인해 甲이 손해를 입음

설문(1) (10점)

사실관계

1심 청구 - 적극적 손해 3000만원 / 소극적 손해 X / 정신적 손해 1000만원 청구

1심 판결 - 적극적 손해 3000만원(전부인용) / X / 정신적 손해 500만원(일부 인용)

물음

이 경우 甲은 항소심에서 재산적 손해배상 청구액을 5천만 원으로 확장할 수 있는지 검토하시오. (10점)

답변

불법행위에 의한 손해배상청구는 각각의 손해별로 소송물이 되지만, 1심에서 전부승소하더라도, 판결확장시 기판력에 의해 별소제기가 불가능하므로, 청구확장이 가능하다.

설문(2) (10점)

사실관계

甲과 乙사이 1,000만 원 소송상화해 성립, 화해조서 작성.

甲의 乙강박을 근거로하여 화해조서가 무효임에 대한 확인을 구하는 소제기.

물음

‘이 소’는 ‘받아들여질 수 있는지’를 검토하시오 (10점)

답변

재판상화해는 순연한 소송행위이고, 실체법상 하자를 이유로 효력이 부인되지도 않고, 무제한으로 기판력이 발생하는 바, 화해조서무효확인 소는 받아들여질 수 없다.

*첨언 - ‘10점’이기 때문에, 화해까지만 기재하고 다음 설문으로 넘어감이 바람직합니다. ‘물음’을 보았을 때, 확인의 이익을 충분히 논하여 줄 수 있고, 잘 작성하면 추가득점도 가능할 것으로 생각되지만, 현실적으로 시간 압박 속에서는 작성하기 쉽지 않았을 것으로 보입니다.

설문(3)(10점)

사실관계

乙이 서명한 손해배상각서(사문서) 甲에게 교부

교부된 손해배상각서에 액수 부분이 비워진 채(백지문서) 교부

乙주장 “서명은 자기 것이 맞으나, 甲이 액수를 무단 기재” 하여 “증거로서 효력이 없다” .

물음

법원은 ‘이 각서를 증거로 인정하여’ 乙에게 ‘5천만 원의 지급을 명’ 할 수 있는지 설명 하시오.(10점)

답변

각서는 사문서이고, 사문서의 2단계의 추정에 의해서 형식적 증거력이 추정된다. 그런데, 백지문서인 것이 밝혀지는 경우, 형식적 증거력의 추정이 복멸되는데, 본증으로 입증되어야 한다. 그러한 사실이 없는 바, 형식적증거력이 추정되고 실질적 증거력도 추정되어 법원은 지급을 명할 수 있다.

*첨언

답이 갈릴 수 있는 문제로 보입니다.

문제 사실관계가 불분명한데, 10점 분량에 맞추어 답하기 위해서는, 출제의도는 백지문서임 이 법원에 밝혀져 증명된 것으로 가정하는 것도 타당해보입니다.

이상적으로는 실질적 증거력까지 언급하여 지급을 명할수 있다는 결론을 내리는 것이 좋겠으나, 수험장에서 불분명한 사실관계라 판단되는 경우에는, 양 경우를 가정하고 포섭해주는 등의 정도로 방어하셨으면 좋았을 것 같습니다.

서명과 관련하여 보조사실의 자백도 논의할 실익은 크게 없으나 작성 가능하고, 백지문서임에 법원에 증거로 제출되어 증거로 채택되는지 여부와 관련해서 甲이 부인, 부지 등으로 답변한 사실이 존재하지 않습니다. 또한, 백지문서가 본증으로 증명되었다는 사실관계도 존재하지 않습니다.

또, 5천만 원의 지급을 위해서는, 처분문서가 형식적 증거력이 존재하면, 실질적 증거력이 추정되므로, 지급을 명할 수 있다는 논리를 작성하기 위해서, 사문서의 실질적 증거력도 작성가능합니다.

【 문제-2 】 (20점)

공통사실관계 : 甲이 乙을 상대로 2억 원의 대여금반환청구소송 제기 예정.

설문(1) (10점)

사실관계

‘乙의 주소지 관할법원’ 로 하는 관할합의

乙이 A에서 B로 이사함

甲은 의무이행지 관할법원을 근거로 A법원에 소장 제출

물음

A법원에 이 소의 관할권이 있는지를 검토하시오. (10점)

답변

乙의 주소지 관할법원에 전속적관할합의가 성립되었으므로, A법원에는 관할권이 없다.

*첨언

소 제기시를 기준으로 관할합의가 성립된다는 사실관계가 다른 판례도 존재하여, A법원에 전속적관할합의가 성립되었다는 논리도 일응 타당합니다.

하지만, 문제의 마지막 물음 전에, 의무이행지 법원에 소 제기한 것으로 보는 뉘앙스가 있어서, 일단의 출제의도는 B 법원에 전속적관할합의의 효력이 유지되고 있다고 가정하고 풀이하시는 것이 타당한 것으로 사료됩니다.

설문(2) (10점)

사실관계

2억 원의 대여금 반환청구의 소 C지방법원 단독판사 1심 판결

항소 후 C지방법원 합의부 2심 진행 중 5억 5천만 원 반소 제기

물음

이 경우 법원은 C 지방법원의 상급법원인 D고등법원으로 사건을 이송하여야 하는지 여부를 설명하시오. (10점)

답변

사물관할은 1심 전속관할로 관할변동에 영향없으니, 이송할 필요 없다.

【 문제-3 】 (30점)

공통사실관계 :

제1의 소 - A소유권이전등기 갑이 을에게

제2의 소(추가적 병합) - A토지 수용을 조건으로 한 금원의 지급을 구하는 소

설문(1) (10점)

물음

‘제1의 소가 항소심 계속 중’ 일 때 ‘이러한 제2의 소를 추가’ 하는 것이 ‘가능한 이유’ 를 설명하시오 (10점)

답변

청구의 객관적 병합의 요건을 만족하고, 항소심에서 청구변경의 요건을 만족하는바, 항소심에서 청구변경 가능하다.

설문(2) (10점)

사실관계

제2의 소의 조건인 변론종결시까지 ‘A토지 수용 여부’ 확정되지 못할 것으로 예상됨

물음

‘그럼에도 불구하고’ 이러한 ‘제2의 소를 제기할 수 있는 이유’ 를 설명하시오 (10점)

답변

대상청구의 병합은 가능하다. 그리고, 사실심변론종결시까지 조건이 달성되지 않아, 장래의 이행을 구하는 청구가되는 경우에는, 장래이행의 소로서 적법하여 제기할 수 있다.

*첨언 - ‘10점’ 이기 때문에, 대상청구 중, 이행불능을 대비한 예비적 병합 등을 논하기 보다, ‘그럼에도 불구하고’ 라는 문구에서 장래이행의 소를 검토해주는 것이 이유를 설명하는데 적합한 답변입니다.

설문(3) (10점)

사실관계

항소심 제1의 소, 제2의 소 모두 인용

제2의 소에 대해서만 상고

물음

‘제1의 소에 대한 판결에는 상고하지 않았으므로 이 판결은 확정되었다.’는 이유로 A토지에 대한 소유권이전등기절차를 실행할 수 있는지 검토하시오(10점)

답변

제1의 소에 대해서는 상고하지 않았으나, 상고심판결이 선고되어야 불복하지 않은 부분이 확정된다. 따라서, 이전등기절차를 실행할 수 없다고 할 것이나, 상고심판결이 선고되면 의사진술을갈음하는 판결을 통해 이전등기절차를 실행할 수 있을 것이다.

【 문제-4 】 (20점)

공통사실관계 :

乙이 丙에게 5천만 원 대여, 甲소유 A토지에 저당권설정등기.

설문(1) (10점)

사실관계

甲주장 "丙에게 대리권 수여사실 없음."

乙주장 "甲이 丙에게 대리권 수여했음."

법원판단 -> 대리권 수여 사실 없음

법원 증인신문 -> 저당권설정행위 추인사실을 알게됨, 하지만 乙은 주장한적 없음.

물음

‘이러한 경우에 법원은 ‘i) 甲이 丙에게 A 토지에 대하여 저당권을 설정할 수 있는 대리권을 수여한 사실은 없고, ii) 丙이 대리권 없이 한 저당권설정행위를 나중에 추인하였다’고 판결을 할 수 있는지 검토하시오.(10점)

답변

변론주의에 의해, i)대리권수여사실은 판단할 수 있으나, ii)당사자들이 주장하지 않은, 추인사실에 대해서 법원은 판단할 수 없다. 이에 근거하여 판결할 수 없다.

* 첨언

문제의 사실관계에서, “법원은 甲이 丙에게 대리권을 수여한 적이 없다고 판단하였다.”라는 기재를 통해서, 등기의 법률상 추정은 직접적인 출제의도가 아님을 알 수 있습니다. 이는 진위불명인 경우 문제될 수 있는 입증책임을 굳이 논의해주지 않아도 됩니다. 문제의 마지막 물음을 통해서 변론주의를 타겟팅한 문제라고 생각해주는 것이 바람직했겠습니다.

또한 변론주의 상, 묵시적 주장과 간접적 주장과 관련된 판례가 있으나, 이를 작성하면서 기재하는 경우에 물음에 대한 답변으로는, 사실관계가 불분명하여 석명권(소송지휘권)을 행사하고 판결해야한다고도 답변이 가능해집니다.

설문(2) (10점)

사실관계

1회 변론 기일

甲주장 "丙에게 대리권 수여사실 없음."

乙주장 "丙에게 대리권 수여사실 없음, 그러나 저당권설정을 추인함."

2회 변론 기일

乙주장 "丙에게 대리권을 수여하였음."

물음

이와 같이 乙은 ‘甲이 丙에게 A 토지에 대하여 저당권을 설정할 수 있는 대리권을 수여한 적이 없다’고 한 진술을 철회할 수 있는지 검토하시오. (10점)

답변

재판상자백이 성립하였고, 자백을 철회할 수 있는 사유도 보이지 않는 바, 철회할 수 없다.